



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000232530

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1128918-74.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA SUZETE GOMES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FABIANO CORDEIRO DE LIMA.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.

São Paulo, 5 de abril de 2017.

Egídio Giacoia
Relator
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO nº 1128918-74.2015.8.26.0100

APELANTE: MARIA SUZETE GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: FABIANO CORDEIRO DE LIMA

INTERESSADOS: MARIA EDUARDA GOMES DO NASCIMENTO DE LIMA E ANA CLARA NASCIMENTO DE LIMA

COMARCA: SÃO PAULO

VOTO Nº 29416

APELAÇÃO – Guarda de menores – Pai em face da genitora – Procedência – Laudos conflitantes quanto à atribuição da guarda – Alegação de abuso sexual por parte do atual companheiro da mãe afastada pelas provas dos autos – Genitor que, mesmo possuindo melhores condições financeiras, possui histórico de agressão contra a genitora, pratica alienação parental, e não se preocupa em manter os vínculos entre mãe e filhas – Questão financeira que não pode prevalecer sobre os elevados interesses das crianças – Prevalência do Estudo Psicológico mais recente, que também norteou o judicioso parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça – Decisão modificada - Guarda que deve ser atribuída à mãe, invertido o regime de visitação. Recurso Provido.

Trata-se de ação de regulamentação de guarda das menores M. E. G. do N. de L. e A. C. G. do N. promovida pelo genitor F. C. de L. contra a mãe M. S. G. do N.

A r. sentença de fls. 235/237, proferida pelo Magistrado **HOMERO MAION** e aclarada a fls. 242, cujo relatório adoto, julgou procedente o pedido para atribuir a guarda unilateral das menores ao genitor, fixando as visitas da mãe em finais de semanas alternados, com retirada às sextas-feiras, a partir das 18hs, e entrega na segunda-feira, diretamente na escola.

Recorre a mãe alegando, em apertada síntese, que a principal alegação para o ajuizamento da presente demanda era um fantasioso abuso



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

sexual sofrido por uma das menores, pelo companheiro da apelante, o que ficou comprovado nos autos nunca ter ocorrido. Afirma que a conduta do autor, juntamente com sua companheira, é apenas acabar com a responsabilidade pelo pagamento da pensão alimentícia, vez que já tramita execução de alimentos. Reforça que o laudo pericial afastou essa insinuação, sendo que no dia 21/11/2015, ao comparecer à Ama Vila Oratório, o médico sequer examinou a menor e apenas fiou-se nas informações do apelado e sua companheira. Informa que o genitor possui vasta ficha criminal, respondendo por vários delitos, e que a filha menor T. G. do N., cuja guarda provisória foi concedida pelo Juízo da 8ª Vara da Família e Sucessões, voltou a residir com a genitora. Aduz que o genitor sempre manteve vários relacionamentos amorosos, não se podendo ter certeza que a atual companheira continuará cuidando das menores. Afirma que a assistente social privilegiou no seu estudo apenas o lado material, desprezando o emocional da recorrente e das crianças. Repisa que os resultados dos laudos do processo foram conflitantes. Aponta cerceamento de defesa pela não realização de audiência de tentativa de conciliação. Requer, então, o provimento do recurso para atribuir a guarda das menores à mãe.

Recurso tempestivo e isento de preparo.

Contrarrazões a fls. 257/261 pelo improvimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público a fls. 265/267 pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça a fls. 273/281 pelo provimento do recurso para deferir a guarda das menores à genitora.

Certidão a fls. 285 de decurso do prazo sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.

Com a devida vênia, deve ser integralmente acolhido o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça de fls. 273/281 a fim de dar provimento ao recurso.

Na hipótese dos autos, a pretensão inicial busca a fixação da guarda das filhas menores (5 e 6 anos) em favor do genitor e vem amparada na alegação



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de que uma delas se queixou de dores na genital, o que levou à indicação de que sofrera abuso sexual pelo atual companheiro da mãe.

Pois bem.

Como já consignado na r. sentença, e reforçado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, as provas dos autos afastaram de forma bastante segura a alegação de abuso sexual.

A perícia do Instituto Médico Legal de fls. 122/124 descartou a conjunção carnal e concluiu também não haver evidências que comprovem a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjunção carnal em relação à criança.

Os laudos da Assistente Social e da Psicóloga também refutaram essa ocorrência.

A Assistente Social consignou que o abuso do padrasto não ficou caracterizado vez que a menina M. E. se afigurou pueril e não apresentou gestos, palavras ou maneirismos sugestivos de que houvesse sofrido abuso, além da indignação comovida e aparentemente genuína do padrasto ao falar do assunto (fls. 154/166).

A Psicóloga observou que a menor demonstrou comportamentos característicos de crianças de sua faixa etária, não apresentando indícios de sexualização precoce, sem relato de mudanças em seu comportamento ou sintomas que possam ter surgido após o suposto abuso. Além disso, ressaltou como bastante relevante a informação dada pela própria companheira do genitor no sentido de que a menor M. E. continuou acompanhamento médico devido a queixas de ardência na região da vagina e uma manifestação semelhante a um corrimento, mesmo depois de meses já residindo com o pai (e afastamento do convívio com a mãe e o padrasto), o que é indicativo de que essas manifestações orgânicas não tinham nenhuma relação com suposto abuso (fls. 193/205).

Portanto, o alegado abuso sexual foi repellido por todas as provas dos autos.

Superada essa questão, o que temos são dois (02) Laudos conflitantes quanto à quem deveria ser atribuída a guarda das menores (sendo



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

que nenhum deles confirma o abuso sexual).

Em resumo, o Laudo Social foi contrário ao retorno das crianças aos cuidados da mãe em razão de sua condição social, ao passo que o Laudo Psicológico contém séria indicação de prática de alienação parental por parte do genitor, recomendando a atribuição da guarda à mãe, que sempre cuidou bem das crianças.

A r. sentença se amparou no estudo social e reconheceu que, mesmo não havendo elementos para afirmar que as crianças sofriam qualquer tipo de abuso morando com a mãe, o genitor teria melhores condições de abrigá-las, considerando especialmente que as menores já se encontravam sob a guarda provisória do pai há mais de 6 meses.

No entanto, como bem colocou a d. Procuradoria Geral de Justiça, as meninas não foram para os cuidados do genitor por ato voluntário materno, e sim em razão de busca e apreensão, concedida diante da notícia de suposto abuso sexual, que foi descartada pela prova dos autos (fls. 277).

E “... a avaliação psicológica feita posteriormente ao estudo social, depois de algumas visitas das meninas à casa da mãe, e o referido temor das filhas em relação à possibilidade de volta para a casa da mãe — preponderante para a conclusão social, foi assim afastado:

'A mudança de atitude das crianças com relação ao convívio com a mãe foi outro fator de extrema relevância durante o estudo. Se na primeira entrevista com as crianças, M. E. verbalizou que gostava mais do pai do que da mãe, que não queria mais morar na casa desta, e tampouco voltar lá para vê-la, no transcorrer de nosso estudo, à medida que as visitas maternas foram ocorrendo, houve visível reaproximação entre as filhas e a mãe. A. C. chegou a verbalizar que queria voltar a morar com a mãe e passar mais tempo lá ('A gente vai poder ficar mais com a mainha mãe? Queria que a gente pudesse dormir lá') dizendo com intensa carga emocional: 'gosto muito da minha mãe, e tenho muita, muita, muita saudade da minha mãe'” – (fls. 278/279).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Além disso, o mesmo Laudo Psicológico aponta que o relacionamento entre os genitores sempre foi pautado por violência doméstica (o que não foi negado pelo genitor), e que o genitor e a madrasta não preservam a imagem da genitora, incidindo em alienação parental.

Há conclusão no sentido de que essas condutas podem trazer severos prejuízos ao desenvolvimento das crianças na medida que incutem ideias negativas a respeito da genitora (fls. 202).

E como bem concluiu a d. Procuradoria Geral de Justiça:

“Pelo teor aprofundado da prova psicológica, além de trazer fotografia mais recente do quadro familiar, ficamos aqui, ao reverso do que se decidiu monocraticamente, com a conclusão da perícia psicológica, que deveria, ao nosso ver, ter norteado a decisão do juízo: 'Entendemos, assim, que M. E. e A. C. não viviam em situação de risco, negligência ou violência na residência materna. Todos os elementos levantados durante este estudo nos levam a supor o equívoco quanto à ocorrência do abuso – alegação esta culminou na mudança de guarda das crianças, ainda que provisoriamente, ao pai. A partir de nossa análise sugerimos que M. E. e A. C. voltem a residir com a mãe, que apresenta condições de prestar-lhes os cuidados e assistência necessários para um bom desenvolvimento'

(...)

A genitora se mostra mais continente em relação às filhas, embora socialmente tenha condições mais precárias, validando-as emocionalmente, ao reverso do genitor, que aparenta inconformismo com o novo relacionamento materno, era pessoa dada a violência doméstica, não parece proteger as filhas em seus aspectos mais íntimos da emotividade, notadamente ao desqualificar a genitora, sem poupar as crianças. Na ponderação de interesses, as filhas ficarão melhor com a mãe, que nunca as afastou do pai, mesmo depois da ruptura familiar” – (fls. 280/281).

E ainda deve ser ponderada a informação constante a fls. 202 do laudo da Psicóloga de que o genitor pretende se mudar de São Paulo para o



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Nordeste do país em busca de melhores oportunidades, deixando claro na entrevista que não se preocupa quanto à manutenção dos vínculos entre a mãe e as filhas.

Por tudo isso, e respeitado o entendimento do d. Magistrado, penso que a melhor situação financeira do pai não pode prevalecer sobre os superiores interesses das crianças, devendo ser considerado o histórico de agressão física e emocional, bem como a clara indicação de alienação parental pelo genitor.

Muito especialmente deve também ser ponderado que não há nada nos autos a desabonar os cuidados que a mãe sempre manteve com as crianças, mesmo depois da ruptura familiar, sendo certo que também nunca as afastou do pai (e o contrário não pode ser dito).

Assim, e acolhendo integralmente o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, o recurso merece provimento para, dentro do aspecto dúplice desta ação, atribuir a guarda das menores à genitora, invertendo-se o regime de visitas fixado na sentença em favor do pai.

Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso.

EGIDIO GIACOIA
Relator